壹、公同共有（§1151）

一、立法例

1、分別共有主义

2.公同共有主义（§1151）（SC30渝上202例）：不得按应繼分清償或單独受領（SC74台上748例）

二、管理

1、§1152得由繼承人中互推一人管理之

(1) 基於委任契約而生 ⇒ 其他繼承人得依§549Ⅰ隨時終止（SC30上1955例），回復共同管理

(2) SC33上344例：有請求租金及返還租賃物之权，未互推一人時如得公同共有人同意亦可單独行使之

(3) 注意义務 ⇒ 法无明文 ⇒ 解為§1176-1具体輕過失

2、由§828Ⅱ $\xrightarrow{準用}$ §820Ⅰ 过半权同意為之

三、孳息：管理人收取、行使收益权，但仍歸屬公同共有人

四、处分

1、§828Ⅲ全体同意

2、SC33上1196例、576例：繼承人同居一家其中一人任家長，因清償共同負担債務而有处分遺產必要時，必要限度內可推定已得全体同意

3、无权处分恶意第三人（善意自有§801+948、§759-1Ⅱ保护）

(1) 效力未定說：須其他共同繼承人承认（林）

(2) 无效說：得对第三人提确认該物仍屬公同共有人之訴（SC37上7302例、史、戴、棋）

4、不动產登记

(1) 土登規則§120Ⅰ、SC69台上1166例：原則為公同共有登记，全体同意始得申請分別共有登记

(2) 公同共有轉登记分別共有係变更共有性質 ⇒ 处分行為之一种 ⇒ §828Ⅲ全体同意

5、应繼分

(1) 分割前不得單独让与說：我國无优先承買或贖回权規定，且前制度弊多利少，於財產債权化之現今无必要（范揚、劉鍾英、林）

↳ 公同关係存續時不得自由处分（通、SC89台再81）

(2) 須全体同意說：第三人加入共同关係非法所不許且同意後无不可之理由（棋）

(3) 不区分受让人說：全权同意後，亦可让与其他公同共有人（戴）

(4) 区分受让人說：对內得自由处分因債務本即負連帶責任故对外关係不变无限制之理，但对外須全体同意（史）

(5) 原則得自由轉让說：顧及權之流通性 ⇒ 避免禁止分割之遺囑過苛（鼎）

(6) 折衷說＝代理处分說：允许委任第三人以代理方式參与分割，且分割前得处分但他共有人有优先回贖之权限（胡）

(7) J562：不动產处分得依土地§34-1Ⅴ $\xrightarrow{準用}$ Ⅰ多权決

(8) SC105台上1959：仍应以应繼分為潛在应有部分，超過部分之权利自屬§179

五、債務（SC105台上686：义務屬遺產，亦為分割之标的）

1、外部关係：連帶責任（§1153 I）（SC105台上980裁：非公同共有債務）

(1)有§273（SC27渝上2587例）

(2)全体同時对一債权人負有債務，僅起訴其中一人，因連帶債務係独立訴訟标的⇒判決之既判力不及他繼承人（SC26渝上247例）

2.內部关係：按應繼分比例負担（§1153 II ⇒ §280之特別規定）

(1)應繼分：含法定及指定應繼分

(2)非強制規定，得特約排除（ex：§1171）

(3)有§281內部求償权之適用

3.SC103台上1785：因遺產所生之稅捐或費用按應繼分負担之，一人墊支者，对他共有人屬§179⇒公法上納稅义務无明文連帶⇒无§281

貳、分割

一、分割之自由：雖§829不得請求分割，惟為使物盡其用、貨暢其流⇒§1164本文 隨時請求分割（§829之特別規定）

二、限制（§1164但）

1、§1165 II 禁止分割遺囑

(1)須以遺囑為之，生前之禁止无效

(2)受委託為分割方法之指定人（§1165 I）⇒不得為禁止之指定，否則違背委託人意思

(3)期限：~74，20年 ⟶ 74~10年 ⟶ 115立法草案，5年⇒超過仍有效⇒縮短至10年，不須受限可信託（信託§2）（通）↔全部无效說

(4)違反遺囑而分割

A、有效說（林）：所有权絕对原則+契約自由原則+物盡其用 >遺囑自由原則⇒全体同意後自无不許之理

B、得分割惟不得變更為分別共有之登記（史）

C、否定說（黃詩淳）：架空遺囑，除違反公序良俗外均應原則禁止

2、不分割之契約⇒期限？

(1)消極說（戴、琛、范揚）：民法无限制，且民間有存留田宅之一部為祀產（祭祀公業、祭田等）⇒永久禁止分割无違公序良俗，无不許之理

(2)類推§823 II 說（胡、鼎）

(3)類推§1165 II 說（史、楨、林）：§830未準用§823，遺囑自由及契約自由應同向所有权絕对原則退让⇒§1165 II 性質相近

3、§1166胎兒應繼分之保留

(1)胎兒之法代（§1166 II：母）：胎兒繼承時父已死亡⇒§1086生母為法代/兄姐死亡父母均拋棄⇒？

A、有父代理必要時，母得委任父為之，適用上无感受重大困難（劉鍾英）

B、畫蛇添足，違反男女平等、BIOC並生疑難，應刪除（林）

(2)未保留胎兒應繼分而分割遺產之效力：无論分割前後得知⇒違反禁止規定无效，死產則仍屬有效（林、史）

A、115修正草案：胎兒出生後始得分割（林、戴、楨、Ger立法例）

B、救濟

(A) 由特別代理人請求重行分割说 (棋)

(B) 法代得行使 §1146I 繼承回復請求权说 (通)

(C) 法代(母)得請求重行分割说 (史、戴)

(D) 分割自始无效说：若遺產於原狀則請求重新分割，否則請求 §1146 (范揚)

(E) 权利同時併存说 (林)：分割請求权屬形成权；§1146 通说认係請求权，有時效限制 ⇒ 权利性質迥異，同時併存

↳ 胎兒与其母同為繼承人時須 §1086II 特別代理人

三、方法

1、遺囑指定分割 (§1165I)

(1) 被繼承人指定

A、可指定一部，亦可对部分繼承人指定，未受指定者仍可協议或請求裁判分割

B、原物分割、換價分割、原物分割兼金錢補償、代償分割、部分原物部分換價分割均可

C、縱變更應繼分，可以指定應繼分 (21院741、SC 99台上918) ⇒ 不罹於時效 ⟷ 遺贈為債权效，有時效，不得代位

(2) 委託他人為分割之指定

A、他人之定义

(A) 包括繼承或受遺贈人说 (史、林)：文义解釋 (他人而非第三人)

(B) 繼承人不得代為指定應繼分说 (胡、棋)

B、分割方法顯失公平者得請求重行分割 (史、戴、棋、林)

C、受託人有接受与否之自由 ⇒ 類推 §1170II 繼承人得催告確答 (史、棋)

(3) 是否有使受益繼承人单独取得所有权，進而单独辦理繼承之效力

A、肯定说 (SC 97台上2217)：尊重遺囑人之意思 ⇒ 使其具物权效

B、否定说 (黃詩淳)：避免破坏遺產之一体性，形成紛爭複雜化，遺囑真偽不明下，不宜貿然賦予如此強烈之效力

2、協议分割

(1) 性質：契約

A、SC 54台上2664例：協议後除非所有人皆同意重行分割外，不許任何共有人再主張分割

B、SC 73台上4052例：不要式行為，与共有物分割之協议同屬債权行為

C、舊 §1167 分割溯及於開始繼承時生效 (SC 32上3897例—不再援用) ⇒ 現採移転主义，无溯及效力

(2) 当事人

A、須全体繼承人參与，排除部分人者，協议无效

B、无行為能力人：法代代為協议；限制行為能力人：協议應得法代允許 (SC 40台上1563例)

C、胎兒 (§7Ⅰ)

(A) §1166Ⅱ：母為代理人

(B) 舊法若有利益衝突 ⇒ SC20上954例另定監護人 (林：§106效力未定 / 戴、棋：无效)

(C) 新法利益相反 ⇒ §1086特别代理人

(3) 方法

A、§824Ⅱ原物 or 換价分割，但无須考量債務 (債務有§1153)

B、§1171Ⅰ得移歸一定之人承受 ⇒ 内部协议，对外除非債权人同意否則仍負連帶責任 (§1171Ⅰ)

C、SC68台再44例：全体共有人自由意思同意 ⇒ 无否定其效力之必要 ⇒ 自由之意思於协议分割上应更重於平等之理念

(4) 時效

A、分割請求权屬給付之訴，為債权請求权 ⇒ §125：15年

B、SC 69第8次民庭决议、81台上2688例：時效將使公同共有无消滅可能，揆諸§1164物盡其用之立法精神，应许其提起裁判分割

3、裁判分割

(1) SC29渝上472例、類推§824Ⅱ：須先行协议，不得逕為訴訟

(2) 不能协议：协议不能 or 困難 or 不成立 (ex：对分割意見不一致、行蹤不明、重病、权人私占遺產拒絕分割請求)

(3) SC 59台上1198例：已协议即不得再請求裁判

(4) SC 107台上87、104台上521、1077：分割方法应以遺產整体為之，非以遺產中個別財產為分割对象

(5) 方法：原物分割、变价分割、原物分割兼金錢補償、代償分割 (§824Ⅱ)

A、以原物分割為原則 (史、戴、林、棋)

B、SC 51台上271例：原物分割以不使其減少价值為必要，有困難時始得為变价分割

C、林：§824Ⅲ不失為好方法

(6) 性質

A、SC 107台上87：分割請求权兼有形成及給付之性質，非繼承人一身專屬权，得代位行使

B、通：同意分割之人一同起訴，反对之其他人為共同被告 ⇒ 固有必要共同訴訟

C、SC51台上2641例、通：形成判決說

D、SC 75第1次民庭決议：兼有形成判決及給付判決之性質，因強執§131有執行力

E、林：強執§131僅賦予分割裁判執行力之特别規定，不因其改变訴之性質，且各所有人分管之部分判為其各单独所有時无須負交，僅具形成之性質

F、SC 29渝上1792例；114台上331：法院得自由裁量分割方法，不受当事人主張約束 ⇒ 分割前无法預知分割結果 ⇒ 无從表明应給付內容，屬形成之訴

四、扣还 (§1172) (ex：3人繼承300万，甲欠200万 ⇒ 300+200=500，$500\times\frac{1}{3}=\frac{500}{3}<200$ ⇒ 甲之分配額為0万，欠$\frac{100}{3}$万) (SC103台上235裁：分割時应优先減扣清償)

1、被繼承人对繼承人之債权於共有人間形成準共有关係，无混同 ⇒ 分割時方便而有§1172債額由应繼分內扣去

2、債務＞应繼分 ⇒ 仍应償还超过部分，拋棄繼承已非繼承人，但仍為債務人

3、債权：非立法疏漏 ⇒ 此係权利非义務，繼承人得拋棄債权，法律应听其自由 ⇒ 林：方便实行，亦可參考§1172立法精神先由遺產扣去債权額

五、生前特种贈与之歸扣（§1173）

1、立法意旨

(1) SC27上3271例—停：被繼承人通常无使該繼承人特受利益之意思，不過因此等事由就其日後終应繼承之財產預先撥給而已
⇒除被繼承人於贈与时有反对之意思外，应將贈与价額计入繼承开始时，為应繼財產

⇓

(2) 通：此類贈与係被繼承人不過便宜上為应繼分之前付，非利於受贈人之意思為之 ⇒推測被繼承人之意思以於应繼分扣除為妥

(3) 立法例：充当计算主义（將价額计入繼承开始时被繼承人所有財產中為应繼財產）（SC 54台上2912例）⇔現物充当主义

2、标的

(1) 特种贈与：列举規定（SC 27上3271例、95台上2781、通）

A. 因表面上為贈与，实質上為应繼分約定 ⇒ §87Ⅱ通謀之隱藏行為（林）

B、死因贈与

(A) 通：係歸扣标的

(B) 林：非生前特种贈与，因死因贈与以死亡為前提，与应繼分前付之性質不符，且通自认特种贈与非特留分扣減之标的，但死因贈与屬之

(2) 贈与物已滅失

A、通：仍应歸扣 ⇒充当计算主义，以受贈时之价額為计算标準 ⇒不問有无过失 ⇒不將自己或第三人之过失轉嫁其同繼承人

B、林：兼顧公平性，原則应歸扣，但不可抗力（天災地震）致毀損又无保險时即无責任轉嫁考量 ⇒縱未移転亦因环境毀損，无期待利益不歸扣

3、义務人

(1) 拋棄繼承人

A、不必歸扣说（戴、史、SC 31.11.19民庭总決议）（批评：不公平）

(A) 戴、SC 31.11.19民庭总決议：限承认繼承人，不問限定或单純承认，縱受贈亦与繼承不生关係（已非繼承人）

(B) 史：可推定此时特种贈与有給予其享受特殊利益之意思 ⇒屬一般无償贈与，免返还亦免歸扣

B、須歸扣说（鼎）：应繼分之前付，不得藉由拋棄繼承免其义務（批评：无应繼分，何以扣除）

批评：特留分扣減标的限死後处分（遺贈 / 指定应繼分）
↑

C、須扣減说（楨、胡）：无須歸扣，但应先加入总額中计算有无侵害到他人特留分，允许他繼承人類推行使§1225特留分扣減权

D. 不必歸扣但須負返还責任说（林）：应繼分之前付性質不变，拋棄时即失去接受应繼分前付之权利基礎 ⇒ §179不当得利返还

(2) 喪失繼承权

A、区分说（戴）：繼承人无直血卑时无須歸扣，若有代位繼承人則歸扣（批评：对代位繼承人不公平，亦違反制裁不正行為人之立法目的）

B、依不当得利返还说（林）：同前

(3) 代位繼承人從被代位人受特种贈与

A、均須歸扣说（通、SC111台上757）：§1140代位人承襲被代位人之应繼分（§1140），包括应繼分之前付，且其已死亡，不再適用§179

B、无須歸扣说（振）：代位繼承係固有权，且歸扣义務人限受贈並承认繼承之本人

(4) 代位繼承人受特种贈与

A、時期不区分说（戴、楨、通）：文义解釋，且固有权说应從FR立法例，前問題既未区分時期，本处亦应不区分

B、時期区分说（林、胡）：須受贈時已有繼承人地位方須歸扣 ⇒对孫輩之贈与係普通贈与，若歸扣將增加他繼承人本不可期待之利益

4、权利人 (通：不含拋棄繼承人、受遺贈人,因受遺贈人僅得就繼承开始之遺產行使权利§1160)

(1) 狭义说(戴)：未受生前特种贈与之其他繼承人 (对受贈額少者不公平)

(2) 折衷说(模)：同順序繼承人含代位繼承人受特种贈与較少者

(3) 廣义说(林、史)：其他繼承人,不問有无受贈或受贈額多寡

5、免除 (§1173Ⅰ但：反对之意思表示)：所有权絕对原則,尊重被繼承人之意思

(1) 時期

A、无限制說 (戴、模、SC99台上611、111台上745)：尊重被繼承人意思⇒得遺囑免除

B、贈与時說 (林)：法條明文

(2) 撤回

A、肯定說 (史)：免除係不縮小其应繼分,撤回即縮小应繼分,仍屬其自由,肯认之

B、否定說 (林)：撤回指阻止未生效之法律行為發生效力之行為,免除歸扣之意思表示既已生效,自无法撤回

(3) 侵害他人特留分

A、歸扣不扣減說 (戴)：得歸扣但不得扣減⇒僅受贈人不得再因繼承而有所得而已

B、得歸扣扣減說 (模)：即使免除歸扣仍得行使扣減权

C、不生歸扣扣減說 (林、史、21院743、黃宗樂)：§1224不納入特种贈与⇒不得算定特留分⇒无侵害、§1187亦明文遺囑处分遺產時始有侵害可能

六、行使

1、生效之要件

(1) 当然生效说 (史)：无須请求⇒不待权利人行使自繼承开始時生效

(2) 单独行使说 (通)：係形成权須行使生效,得§242代位行使,法院亦須待主張尚能审酌有无贈与,一人主張,所有受贈与人即生返还义務,利及全体 (无主張亦可)

2、分割時不知⇒分割完後請求§179

七、方法

1、順序

1 算定繼承人之所有財產並確定各繼承人所受之特种贈与

2 应繼財產=遺產+特种贈与額

3 按应繼財產及§1141、1144計算法定应繼分額

4 具体应繼分額=max{法定应繼分－特种贈与額，0} (通)，少數：无須取 max

无須返还說

5 剔除超額人,使其不再參与分配

back to step 1 until no one is removed in step 5

ex：100万,5人，A受贈300万，B受贈80万
⇒(100+300+80)÷5=96<300⇒kick A，80<96⇒keep B
↳100万,4人，B受贈85
(100+80)÷4=45<80⇒kick B
↳100万，3人⇒每人33万 ☆

2、贈与額>应繼分

(1) 无須返还說 (通、SC90台上2460、96台上392、76台上1837)：无須返还多餘部分,僅不得再從遺產中獲得分配而已⇒現行民法僅規定扣除

(2) 須返还說 (林、劉鍾英、鼎、范揚)：依平等享受权利之原則,且前說对遺產分配問題未交代⇒徒然造成分配之複雜化

八、效力

1、立法例

(1) 移轉主义 (TW、Swizz、Ger) = 不溯及主义 / 創設主义：分割後所有权相互移轉 ⇒ 特定繼承財產，繼受於他共有人

A、§825 一般共有物分割

B、§824-1Ⅰ

(2) 宣示主义 (JP、FR) = 认定主义 / 溯及主义 / 宣言主义：分割之效力溯及自繼承开始時 ⇒ 直接繼承自被繼承人 (ex：~74§1167)

2、瑕疵担保責任（§1168：分割後各繼承人按其所得部分对他繼承人因分割而得之遺產，負与出賣人同一之責任）

(1) 根據

A、戴：分割係有償行為，自应有瑕疵担保責任

B、林：雖似互易，惟係公同共有主义下无应有部分之概念，終非互易 ⇒ 应為求共有人間公平，性質上為特別的法定責任

(2) 要件

A、瑕疵於分割前即已存在（通）：以問分割時（胡：須於繼承开始前即已存在）

B、繼承人不知瑕疵存在（§351、355）

C、瑕疵非因繼承人之過失而生：係繼承人自己過失則无向他繼承人主張瑕疵担保之理由

D、被繼承人无免除担保責任之意思表示

(A) JP§914明文，TW未明文

(B) 通：应繼分尚可指定，无理由不許遺囑排除其適用之理由 + 遺囑自由优先於公平性

(C) 通：仍須注意特留分之侵害 ⇒ 有§1225扣減权之適用

E、繼承人間无免除担保責任之特約 ⇒ 通說认应同§366

(3) 內容（修法前採宣示主义者认僅有損賠而已，因无所謂契約價金）

A、損賠請求权

(A) 权利瑕疵（§353）自有適用

(B) 物之瑕疵（§360）：未判決前不知瑕疵之物歸屬何人，自无法保証品質可惡意不告知，為免重新分割使複雜化 ⇒ 不受§360限制

B、減少價金請求权（§359）：僅於代償分割、原物分割兼金錢補償有其適用（ex：分得瑕疵遺產，以此減少代償價金）

C、契約解除权（§353、359）

(A) 通：§1165Ⅰ本文 遺囑指定分割方法，宜尊重其意思，不得行使解除权而重行分配

(B) §1165Ⅰ但 遺囑委託指定分割

a、得行使說（楊、戴）

b、不得行使說（林）：本基於被繼承人意思，而尊重其意思之指定非協议 ⇒ 无契約存在 实无從解除

(C) 裁判分割

a、損賠＋減少價金說（戴）

b、僅損賠說（林）：判決有既判力

c、限協議分割且重大至損賠及價金減少尚無法維持公平時：解除契約即重行分割，耗時耗力

(4) 分担比例：按其實際因分割所得者為限，較公平

3、債務人支付能力之担保責任（§1169）

(1) 性質：§1168之例外 ⇒ 排除§352，但以債权存在為前提，不存在則§1168

(2) 時期

A、§1169 I：未附停止條件之債权、已屆清償之債权及不定期限之債权 ⇒ 分割時即得清償 ⇒ 繼承人僅求分割時支付能力有担保之責

B、§1169 II：附停止條件之債权、未屆清償期之債权 ⇒ 清償時債務人之支付能力負担保責任

4、各繼承人有無資力者時担保責任之分担（§1170）

(1) 繼承人中有不能償还其分担額者（§1170本文）

A、不能償还：与§282不同，限無支付能力

B、無支付能力之繼承人死亡，其繼承人有支付能力，可直接向其請求

C、若前述人採限定繼承者，請求权人必無法獲償，仍須依§1170与他繼承人分担其損害

(2) 非因請求人之过失致不能償还（§1170但）

A、过失（ex：早日請求可受償，因怠於請求而繼承人陷於無資力而不能償还

B、請求時尚有一半支付能力，而後無資力 ⇒ 請求权人負担一半，剩餘部分仍由請求权人与他繼承人分担之

5、連帶責任之免除（§1171）

(1) 債权人之同意

A、§697 I 合夥清算應先清償債務，但分割未要求

B、內部§1171 I 不變更外部連帶責任（SC 38台上174例），既債務得免除，舉重明輕亦得免除連帶責任保留債務

C、約定債務劃歸各繼承人承担，債权人同意 則連帶責任免除，各繼承人按其應繼分負担所繼承之債務

D、約定移歸一定人承受，此同意含連帶責任免除及債務承担承认之双重效果

(2) 法定期間之經过（§1171 II：5年）

A、債权已屆清償期者自分割時起算，未屆清償期者自清償期屆滿起算

B、性質

(A) 消滅時效說（胡）：非怠為行使即对承担方式已有相当默契 ⇒ 特設短期消滅時效，排除連帶責任

(B) 除斥期間說（史）：依文句及旨趣观之

(C) 法定期間說（戴、林）：效果僅限免除連帶責任，債权仍存 ⇒ 法定期間較中性

C、經过後由各繼承人按其應繼分承繼之，僅得向各債務人請求 ⇒ 內部之約定屬債权契約，不得对抗債权人（§301）